RENTA – ACTUAL LEY SOBRE IMPUESTO A LA – ART. 41 G – CIRCULAR N° 40 DE 2016 (ORD. N° 757 DE 08.03.2022).

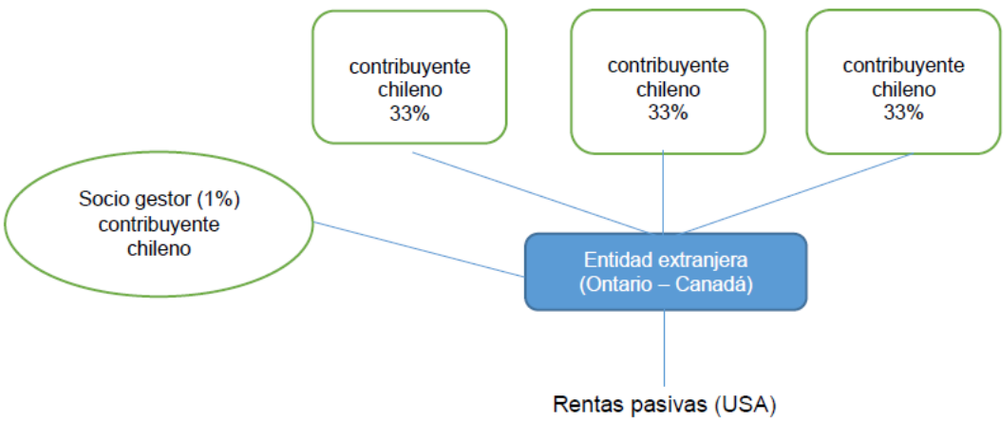
Aplicación del artículo 41 G de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Se ha solicitado a este Servicio un pronunciamiento sobre la aplicación del artículo 41 G de la Ley sobre Impuesto a la Renta respecto de la existencia de control de una entidad extranjera.

I ANTECEDENTES

De acuerdo con su presentación, el artículo 41 G de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR) establece normas para determinar si una entidad es considerada controlada en el exterior. El presente caso se trataría de una sociedad extranjera formada por tres [sic][1] accionistas con domicilio o residencia en Chile con igual participación (ninguno de ellos con más del 50%), en la que solo uno de ellos actúa como director.

La estructura sería la siguiente:



Los socios comanditarios tienen derechos sobre el capital y las utilidades, pero no pueden participar en la gestión o administración. El socio gestor también participa en el capital y las utilidades con un porcentaje minoritario, pero es quien tiene las facultades exclusivas de administración.

Ninguno de los socios tiene facultades individuales para designar o remover al administrador ni opciones de compra sobre la participación de los otros socios.

Al respecto, consulta sobre el significado de la participación de un 50% o más del derecho a voto y si este derecho a voto se refiere a los derechos de los accionistas o de quienes tienen participación en una sociedad o a las facultades de administración que tiene un director o socio gestor. Además, plantea si la entidad externa puede ser considerada como controlada, o si será necesario que tenga más de tres directores para la toma de decisiones.

Finalmente, consulta si se considera que el socio gestor es controlador por el solo hecho de tener la administración de la entidad y si tiene relevancia que el administrador no tenga participación.

[1] La consulta señala que serían tres accionistas, pero según el esquema que acompaña, serían cuatro.

II ANÁLISIS

Para calificar si una entidad extranjera es controlada en los términos del artículo 41 G de la LIR, se deben considerar especialmente los estatutos sociales, los acuerdos de accionistas o de socios, los acuerdos de actuación conjunta, los contratos de asociación y otro tipo de documentación.

El N° 2 de la letra A del artículo 41 G de la LIR entiende que la entidad en el exterior es controlada cuando, por sí o con relacionados[2], se posea, en forma directa o indirecta, el 50% o más i) del capital, o ii) del derecho a las utilidades o iii) de los derechos a voto.

Asimismo, la ley considera que existe control cuando directa o indirectamente, por sí o a través de relacionados, se puede elegir o hacer elegir a la mayoría de los directores o administradores o poseer facultades unilaterales para modificar los estatutos, o para cambiar o remover a la mayoría de los directores o administradores[3].

Por lo tanto, un contribuyente domiciliado o residente en Chile es controlador de una entidad extranjera cuando directa o indirectamente posea más del 50% de los derechos a voto en la misma[4].

Atendido que en el caso analizado el socio gestor (que tendría domicilio o residencia en Chile) tiene las facultades exclusivas de administración de la entidad extranjera, se entiende controlador de la misma para los efectos del artículo 41 G de la LIR.

Lo anterior, sin embargo, no significa que necesariamente se aplique la tributación prevista en el artículo 41 G de la LIR ya que, según lo previsto en el N° 1 de la letra D de la referida norma, para su afectación con la tributación dispuesta en el artículo 41 G se estará a la proporción en la participación directa o indirecta que tenga el propietario.

Al respecto, la Circular N° 40 de 2016 interpretó que por "proporción a la participación" debe entenderse el porcentaje de participación directa o indirecta en el derecho a las utilidades de la entidad y, en caso de no existir dicho pacto, en la proporción en que se haya aportado directa o indirectamente el capital. En los demás supuestos de control contemplados en la norma, distintos de los mencionados anteriormente, se entenderá por "proporción a la participación" el grado directo o indirecto de control efectivo que se tenga en la entidad controlada.

Respecto de los socios comanditarios mayoritarios, de acuerdo con lo descrito en su presentación, ninguno de los supuestos enumerados por la norma citada del artículo 41 G de la LIR parece cumplirse, teniendo en consideración los porcentajes de participación que por sí solos tienen en la entidad extranjera o para modificar sus estatutos o intervenir en la administración en el grado exigido por la norma.

No obstante, si los socios en conjunto están relacionados en los términos de las letras a), b) o d) del artículo 100 de la Ley N° 18.045 también se considerarán controladores, pues en tal circunstancia la disposición legal establece que poseen en forma indirecta el 50% o más del capital o del derecho a las utilidades en la entidad extranjera; circunstancias que podrán verificarse en la respectiva instancia de fiscalización.

Por todo lo anterior, en el caso analizado, y dado que el socio gestor tendría el 100% del control, atendida su calidad de único administrador, será dicho socio gestor quien deba reconocer la totalidad de las rentas pasivas, salvo que se determine que los socios comanditarios también detentan algún grado de control según lo señalado en el párrafo anterior.

III CONCLUSIÓN

Conforme lo expuesto precedentemente y respecto de lo consultado se informa que el socio gestor es controlador de la entidad extranjera, de acuerdo con el artículo 41 G de la LIR, en cuanto posee directamente más del 50% de los derechos a voto de la entidad controlada.

---

[2] Los supuestos de relación aplicables son los establecidos en las letras a), b) y d) del artículo 100 de la Ley N° 18.045, esto es: a) Las entidades del grupo empresarial al que pertenece la sociedad; b) Las personas jurídicas que tengan, respecto de la sociedad, la calidad de matriz, coligante, filial o coligada, en conformidad a las definiciones contenidas en la ley N° 18.046; d) Toda persona que, por sí sola o con otras con que tenga acuerdo de actuación conjunta, pueda designar al menos un miembro de la administración de la sociedad o controle un 10% o más del capital o del capital con derecho a voto si se tratare de una sociedad por acciones.

[3] Oficio N° 236 de 2019.

[4] Circular N° 40 de 2016.

No es relevante que el socio gestor no tuviere participación en las utilidades, si eso fuera posible desde el punto de vista societario, porque en tal caso debe estarse a la proporción en que se haya aportado directa o indirectamente el capital y, en su defecto, debe estarse al grado directo o indirecto de control efectivo que se tenga en la entidad controlada, que en este caso es del 100% por parte del gestor.

Saluda a usted,

FERNANDO BARRAZA LUENGO
DIRECTOR

Oficio N° 757 del 08-03-2022
Subdirección Normativa
Depto. de Impuesto Directos